



FORMAÇÃO DO DIREITO MODERNO

151 minutos

Aula 1 - Direito Feudal e Direito Canônico

Aula 2 - Formação dos Estados Nacionais

Aula 3 - O Direito na Era Moderna

Aula 4 - O Direito na Era Moderna (Teórico)

Referências

Aula 1

DIREITO FEUDAL E DIREITO CANÔNICO

“Idade Média” é o termo utilizado para denominar o período compreendido entre o século V e o século XV na história da Europa.

35 minutos

Imprimir

INTRODUÇÃO

“Idade Média” é o termo utilizado para denominar o período compreendido entre o século V e o século XV na história da Europa. Esse momento histórico se inicia com o fim do Império Romano Ocidental, e terá seu efetivo fim na Modernidade, com a ascensão da burguesia, a implementação do empreendimento mercantilista e a cultura da renascença.

Marcada pelo feudalismo, pela ação das Cruzadas e pela devastadora Peste Negra, a Idade Média apresentou uma série de percepções jurídicas diferentes ao longo dos seus dez séculos de duração, sendo influenciada pelo direito germânico, celta, canônico, romano e feudal, cada qual em maior ou menor grau. No presente texto, estudaremos sobre o Direito Feudal, Canônico e o Renascimento.

VAMOS ESTUDAR SOBRE O DIREITO FEUDAL E CANÔNICO?

O Direito Feudal e o Direito Canônico foram expressões jurídicas presentes na Idade Média, que traduziam as organizações sociais daquela época, bem como suas prioridades político-jurídicas. Destaca-se, de antemão, a forte presença da Igreja Católica que permeou o período medieval e foi evidente no Direito Canônico. A tradição jurídica propriamente feudal era baseada nos costumes e sabe-se que cada feudo tinha suas regras para possibilitar a convivência social. Os costumes que determinavam as relações sociais, contudo, eram direcionados pelos nobres, já que o poder se encontrava em suas mãos, e as tradições eram determinadas pelas origens desses nobres, podendo a influência ser germânica, celta ou latina.

Assim, o Direito Feudal apresentava regras orais e escritas e algumas importantes compilações sobre essa tradição jurídica expressadas em documentos como “Usos e Costumes de Barcelona, a Carta de Pisa”, que remete ao ano de 1142, e o “*Libri Feudorum* de Milão”, de 1095 a 1130. Entre os mais importantes instrumentos jurídicos da época estavam os “contratos de homenagem”: um pacto que se estabelecia entre os senhores feudais e os vassalos. A solenidade desse “contrato” exigia que o vassalo assumisse o compromisso de, inclusive, lutar até a morte para defender o senhor e seus familiares, caso fosse necessário. Desse modo, o Direito Feudal era constituído por uma pluralidade de concepções jurídicas, onde não havia uma hierarquia previamente definida, prevalecendo o direito eclesiástico (Direito baseado em concepções humanas e em “leis divinas”, em um contexto de descentralização e precariedade). Pluralidade jurídica que

seria fundamental, posteriormente, para a formação dos Estados Modernos.

O Direito Canônico diz respeito à tradição jurídica que respeita (como leis) o conjunto de cânones (isto é, regras adotadas pela Igreja) para governar e organizar socialmente a comunidade cristã e seus membros. Essa forma de Direito se confundiu com o Estado por diversas vezes durante a Idade Média. Seus cânones tinham força de lei mesmo para aqueles que não eram cristãos. Contudo, a Igreja jamais negou a existência de dois ordenamentos distintos: um Direito secular e um Direito cristão.

O Direito Canônico apresentava como características, além de seu caráter religioso, seu caráter ecumênico, escrito e erudito, apresentando domínio por uma série de questões de Direito Privado, que se confundiam com os sacramentos da Igreja Católica, tal como a celebração do matrimônio.

Os dois concílios que geraram os primeiros documentos que fomentariam a produção legislativa canônica são o Concílio de Niceia, que remete ao ano 325, e o Concílio de Constantinopla, de 381 d.C.

A centralidade da Igreja Católica somente será contestada com o movimento da cultura renascentista, entre os séculos XIV e XVI, provocando uma forte mudança no pensamento medievo, por meio de um movimento cultural, artístico, científico, político e filosófico, que tinha como base o antropocentrismo.

AS PECULIARIDADES DO DIREITO FEUDAL, DO DIREITO CANÔNICO E O SURGIMENTO DO RENASCENTISMO

A intitulação do feudalismo tem sua origem na palavra “feudo”, derivada do latim e que se associa à ideia de propriedade. Essa palavra sintetiza de forma bastante eficiente os interesses que perpassam as relações sociais da época, já que uma das principais características desse momento histórico foi sua inflexível hierarquia social.

Alguns autores identificam dois períodos feudais: o primeiro deles dura até meados do século XII, e diz respeito ao momento em que a sociedade feudal se organizava no âmbito rural e de forma estável, sendo o comércio atividade incipiente, a moeda ainda não era popularmente utilizada. O segundo período, por sua vez, correspondeu ao momento em que o comércio renasceu na sociedade feudal, havendo a difusão do uso da moeda e o crescimento da importância do comerciante em detrimento do produtor, o que transformou a organização social e econômica (MACIEL; AGUIAR, 2019).

No segundo período feudal, portanto, a burguesia urbana ganha espaço e revoluciona a economia europeia. Contudo, de um ponto de vista social, o modo de produção econômica acaba acentuando a diferenciação dos grupos e classes, que se tornam cada vez mais fechados.

De acordo com (PALMA, 2022), o regime feudal é constituído fundamentalmente na relação estabelecida entre um senhor feudal, da classe dos nobres, e de outro lado, um servo, que ocupa um lugar numa classe social inferior. Diante disso, o servo recebia de seu suserano o *beneficium*, ou seja, a posse do feudo para realizar suas atividades de subsistências, como o cultivo do solo de onde retirará a produção necessária para cumprir todas aquelas obrigações inerentes à sua condição.

O Direito Canônico, por sua vez, se pautava principalmente por seu caráter religioso, que diferenciava a lex aeterna e a lex humana.

A *lex humana* se conserva em uma esfera própria, secular, diferentemente da *lex divina*, que era *aeterna*, sendo a Igreja Católica a entidade designada por Deus para acessar, interpretar e, conseqüentemente, preservar as leis (e a vontade) divina.

Nesse sentido, a lei eterna é a fonte de inspiração da lei humana, da mesma forma que a natureza divina inspira a natureza humana, desse modo, percebe-se uma aproximação entre a natureza humana e a natureza divina, logo, a lei humana também é divina. (BITTAR, 2018)

Ante essa noção, poderíamos entender que toda lei humana seria, também, divina. Contudo, é a imperfeição da criação que torna possível distinções entre as leis. Portanto, o Direito Canônico efetivaria a vontade divina, que somente nele restaria respeitada. Nesse sentido, Bittar (2018, p. 362) sintetiza o pensamento canônico: “a melhor forma de justiça é a ordem que se dá em Deus”.

Lembrando que tal pensamento, centralizado na vontade divina e nos dogmas católicos, somente seria questionado e teria seu fim com o Renascimento, que surgiu na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. No renascimento, o ser humano seria colocado no centro da criação e não mais abaixo da divindade, de tal forma que seu valor e o do divino poderiam ser aproximados.

Esse pensamento refletia o humanismo que foi a principal corrente filosófica da época, junto com o racionalismo, individualismo, classicismo e antropocentrismo.

DIREITO ROMANO CLÁSSICO E PÓS-CLÁSSICO: EXEMPLOS

No Direito Feudal, percebeu-se a presença dos chamados contratos de homenagem, marcados por uma forte solenidade e respeito mútuo, tanto que raríssimas eram as vezes que tais contratos eram desfeitos. Os contratos de homenagem representavam um acordo entre o senhor feudal e seu futuro vassalo. Tal acordo somente era consolidado numa cerimônia chamada “homenagem”.

Nesta cerimônia, ocorria uma espécie de juramento firmado, com a presença de diversas testemunhas e era sempre finalizado com a benção de um sacerdote amigo de um dos nobres suseranos. Ademais, registra-se que o vassalo, então, se colocava de joelhos na frente do seu suserano e lhe jurava a fidelidade até a morte, tal fidelidade referia-se a diversas questões, como de guerrear na defesa de seu senho e familiares, bem como de prover aquilo que for necessário para a subsistência de seu senhor. (PALMA 2022)

Ressalta-se que em tal cerimonia estavam sempre presentes elementos solenetes que caracterizavam tal evento como uma espécie de ritual, na qual reinava um profundo sentimento de religiosidade.

Em relação ao Direito Canônico, citamos o Decreto de Graciano que representou um grande esforço, tal qual Justiniano para os Romanos, em compilar os textos, marcados por uma produção jurídica-normativa da tradição cristã.

O monge Graciano fez um dos grandes feitos para o Direito Canônico em seu esforço de compilar os textos escritos até o momento sobre as relações jurídicas da Igreja, fontes de direito, nomeações e poderes do clero secular e regular, normas processuais nas causas eclesiásticas, crimes e sanções de natureza religiosa, disciplina jurídica dos sacramentos, incluindo aqui os casamentos, que era de competência do clero. O resultado de sua empreitada foi a reunião de quatro mil textos.

Cita-se também o famoso Decreto de Graciano, o qual recebeu, ao lado dos cânones de uma série de concílios e de sínodos locais da Igreja, muitos outros textos de origem pontifícia, como os de Gregório Magno. Ademais, a importância do decreto ocorre, em virtude da presença de centenas de passagens extraídas dos escritos pastorais de importantes padres, como o caso do conhecido Santo Agostinho. Além disso, o decreto também abarcava os textos de direito secular, principalmente de direito romano. (PALMA, 2022)

VÍDEO RESUMO: DIREITO FEUDAL E DIREITO CANÔNICO

Olá, estudante! Esta aula realiza um recorte histórico trazendo as características gerais do direito feudal e do direito canônico após a queda do império romano. O direito feudal, marcado pelo sistema de ordens e o direito canônico, contudo, passam a não ser mais suficientes para solucionar os conflitos de uma sociedade passando por diversas transformações. Por fim, a aula traz mais informações sobre esse renascimento jurídico.

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

 **Saiba mais**

No artigo “ESTADO, DIREITO E RELIGIÃO NA EUROPA MEDIEVAL”, os autores se aprofundam no estudo do pluralismo político que vigorou na Idade Média europeia, envolvendo tradições jurídicas tais como a germânica, céltica, romana etc. O artigo aborda, ainda, o papel da Igreja em relação ao Estado e as características do direito canônico durante a Idade Média na Europa ocidental, até a alteração no panorama geral que permeou a Idade Média, ocorrida durante a Idade Moderna.

Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/historiadireito/article/view/730> acesso em nov. 2022.

Aula 2

FORMAÇÃO DOS ESTADOS NACIONAIS

O presente texto aborda o momento após o fim da Idade Média, em que o Direito sofrerá enormes mudanças, em razão das transformações operadas pelo absolutismo e suas teorias.

27 minutos

INTRODUÇÃO

O presente texto aborda o momento após o fim da Idade Média, em que o Direito sofrerá enormes mudanças, em razão das transformações operadas pelo absolutismo e suas teorias, bem como pelas fortes influências do iluminismo, decorrência direta do movimento cultural renascentista.

Assim surge o Direito Moderno, que emerge das revoluções burguesas e das suas influências internacionais com a quebra do domínio religioso na política.

Assim, com o surgimento do humanismo, desvincula-se o direito e a política dos mitos e predestinações da fé, passando-se a se defender que o homem é o verdadeiro condutor do seu próprio destino, dono de sua própria vontade e único dotado de razão para decidir o seu próprio futuro.

O FIM DA IDADE MÉDIA E SURGIMENTO DO ABSOLUTISMO

Durante a Idade Média e seu contexto de poder descentralizado, o poder “divino” ficou representado muito mais fortemente pela instituição da Igreja Católica do que, de fato, por algum rei ou príncipe. Afinal, por mais que a própria Igreja admitisse que “todo poder emana de Deus”, era certo que o único Deus verdadeiro era representado secularmente, em primeiro lugar, pelo Papa e pelo Catolicismo.

Assim foi que o poder real foi diminuído durante a Idade Média em razão do poder indireto da Igreja Católica, que influía – e muito – nas questões temporais e, até mesmo, monopolizava certos assuntos, tal como o matrimônio, por exemplo. Além disso, a descentralização do poder real durante o medievo também se deveu fortemente em razão “[...] dos senhores feudais, pelos usos e costumes regionais, pelos privilégios das cidades e corporações de artífices” (CICCO, 2017, p. 258).

Assim sendo, no fim da Idade Média, ocorrem inúmeros episódios que levam à morte de nobres – para além da Peste, também, guerras como a dos Cem Anos, Duas Rosas, entre outras – e, frente ao catastrófico cenário de miséria que tinha lugar na Europa, a contestação do poder da Igreja torna-se ainda mais intensa. Nesse período ocorre, também, uma junção de interesses da realeza e da burguesia que conduziram a unificação dos Estados Modernos europeus.

À burguesia interessava a unificação dos Estados em razão da crescente intenção capitalista que se formava com os empreendimentos Mercantilistas, e que fazia surgir a necessidade de criação de uma “moeda nacional” para facilitar o comércio. Além disso, o fim dos impostos feudais e uma reformulação das leis também eram fatores de interesse para os burgueses.

Aos reis e à nobreza, era a invenção da pólvora que deixava o medo de destruição dos castelos medievais e, conseqüentemente, a perda do poder de governo, que levava à necessidade de formação do Estado Moderno, com uma nova forma de organização social.

Foi frente a essa conveniente união de interesses, onde a Igreja Católica já não contribuía, que surgiram os primeiros Estados Modernos sob o regime mais característico do Renascimento: o absolutismo.

A partir de então, constitui-se o Estado Moderno, entendido como um Estado-Nação unificado, e o rei passa a ser sua autoridade máxima, soberana e absoluta. A soberania do Estado Moderno passa a ser interpretada através da supremacia do poder do Estado, que nessa primeira fase absolutista, era representado pela figura do Rei Soberano.

Com essa nova forma de organização política, surgiu-se a necessidade de teorias políticas que explicassem e legitimassem as formas de governo postas. Dessa forma, tornaram centrais as teorias dos contratos sociais que buscavam entender as condições que levaram as pessoas, inicialmente inseridas em um contexto primitivo do estado de natureza a passaram ao estado civil, por meio do firmamento de um pacto de dimensões coletivas. Dentre esses contratualistas destacamos Montesquieu que irá propor pela primeira vez a tripartição dos poderes.

A ORIGEM DO ESTADO MODERNO ABSOLUTA E OS CONTRATOS SOCIAIS

Com o fim da Idade Média, surge uma nova organização política, marcada pela territorialidade e grupos independentes que iriam ser os Estados Modernos. A organização e composição dos Estados Modernos se dá por três principais elementos: o território e o povo, como elementos materiais; o governo, o poder, a

autoridade ou o soberano, como elementos formais. Ainda para alguns autores, há a presença de um quarto elemento, chamado de finalidade. Os autores adeptos a essa corrente argumentam que a existência do Estado precede uma finalidade específica, a qual justifique sua existência (STRECK, 2019).

O uso da nomenclatura “Estado” ocorreu com o filósofo Maquiavel, em seu livro “O Príncipe”, no qual apresentou uma das mais relevantes teorias contratualista para a história, nessa obra ele afirma que: “Todos os Estados, os domínios todos que existiram e existem sobre os homens, foram e são repúblicas ou principados”.

Com efeito, o Estado Moderno representou uma descontinuidade histórica, tendo em vista que se deu através de uma grande concentração de poder nas mãos do soberano, que era expresso, sobretudo, mediante leis, aplicáveis a todo seu território. Ademais, contava também com um aparato coercitivo a fim de fazer cumprir tais leis, de modo que se impunha a todos a vontade do soberano, o rei.

É nesse viés que os teóricos contratualistas buscam desenvolver teorias sobre a origem do estado moderno, cuidando de fundamentar o poder político como decorrência de um acordo social de vontades, que se incumbiu de promover a superação do estado de natureza, ou pré-político, e a instituição da sociedade política, ou civil. Assim, o estado civil funcionaria como uma ferramenta da racionalidade humana, para combater as típicas debilidades do estado primitivo, ora considerado hipótese lógica, ora fato histórico real (STRECK; BOLZAN DE MORAIS, 2019, p. 29).

Cita-se entre os contratualistas Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau e Montesquieu. Os dois últimos foram fortemente inspirados pelas ideias do iluminismo francês, pela liberdade, fraternidade e igualdade e apresentavam teorias críticas à monarquia déspota. Rousseau, por exemplo, foi o primeiro a defender o voto, de modo que a vontade geral tivesse relevância na política.

Somente com Montesquieu e sua obra “*De L’Esprit des Lois*” (1748) que surgiu a percepção da tripartição de poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) de funções como “poderes” independentes entre si. A teoria do filósofo foi essencial para a construção do constitucionalismo atual, conferindo precedentes importantes para a organização do Estado e suas funções independentes e harmônicas.

Nesse sentido, é possível vislumbrar a tripartição dos poderes, enquanto princípio organizativo e fundamental do Estado Moderno, que se tornou, ao longo dos anos, um dos pilares do constitucionalismo. Assim, foi obtida a maior proteção para o exercício dos direitos individuais, através da garantia da liberdade política, um passo fundamental para o desenvolvimento das teorias constitucionalistas que surgiriam depois.

OS CONTRATOS SOCIAIS: EXEMPLOS

Os contratualistas propunham teorias que explicassem a passagem do estado da natureza ao estado civilizatório moderno. Tais explicações poderiam referir-se ao um Estado Absolutista, como no caso de Maquiavel, ou a uma outra forma de estado ausente do despotismo monárquico, como em Rousseau e Montesquieu.

Tem-se como exemplo, a teoria do contrato social de John Locke proposta para o Estado Inglês, a qual defendia a monarquia constitucional e representativa, que entrou em vigor após 1688 na Inglaterra. Para Locke, o Estado funcionava como garantidor da liberdade e da propriedade privada.

Nesse sentido, para Locke haveria um convênio firmado no intuito de resguardar a emergência e generalização do conflito. Através dele, os indivíduos seriam capazes de oferecer seu consentimento para a instauração do

estado civil e, posteriormente, para a formação do governo quando, então, se assume o princípio da maioria (STRECK, 2019)

Um outro exemplo é o contrato social de Thomas Hobbes, também na Inglaterra, defendia a tese de que o Estado seria uma espécie de leviatã, que teria a função de evitar os conflitos e buscar a harmonia da sociedade. Nesse sentido, o Estado deveria representar um poder absoluto. Nesse sentido, até 1679 foi instaurado na Inglaterra uma monarquia absolutista forte.

O pensamento contratualista buscou-se enveredar sobre a busca do surgimento dos Estados e as justificações em torno do seu poder político, através de um pacto social, que teria colocado fim ao estado de natureza, no qual não havia uma devida organização política. Assim, teria surgido o estado civil, como uma representação da racionalidade humana, que, para alguns, representa também o surgimento do homem civilizado. Logo, as teorias contratualistas consolidam-se como instrumentos de legitimação dos Estados, já existentes e a base sistemática de construção do sistema jurídico (STRECK, 2019).

Montesquieu em sua obra “O espírito das leis” reconhece a possibilidade de três formas de governo: monarquia, república e despotismo, de modo que a monarquia se sustenta na honra, enquanto a república estaria assentada na virtude e por fim, o governo despótico no medo. Ainda, o autor acreditava que a monarquia seria a forma ideal.

A grande contribuição de Montesquieu definitivamente ocorre a partir da propositura da tripartição dos poderes. Para ele, em cada Estado coexistem três poderes: o poder legislativo, o poder executivo (poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes, segundo sua terminologia) e o poder judiciário (poder executivo das coisas que dependem do direito civil).

Cada um dos poderes recebe determinadas atribuições, o poder legislativo é o responsável pela confecção das leis, já o poder executivo, ocupa-se o governante da paz e da guerra, envia e recebe embaixadores, estabelece a segurança e previne as invasões, por fim, o poder judiciário dá ao governante faculdade de punir os crimes ou julgar os dissídios da ordem civil (BONAVIDES, 2000).

Montesquieu, ao lado de Rousseau e Voltaire, foi um dos grandes pensadores do iluminismo, tendo em vista que criticava o poder absoluto e a monarquia despótica, tendo como um dos pilares de sua teoria a busca pela liberdade política. Para o filósofo, a ideia básica de liberdade consistia na permissão de fazer tudo quanto permitem as leis.

VÍDEO RESUMO: FORMAÇÃO DOS ESTADOS NACIONAIS

A aula objetiva analisar a formação dos Estados Nacionais, para isso realiza um recorte histórico indicando as características do Absolutismo e a sua superação através do Iluminismo. Verificar-se-á a formulação de importantes teorias sobre o Contrato Social e a separação dos poderes. Por fim, a aula traz mais informações sobre esse renascimento jurídico.

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

Saiba mais

O artigo “A Separação de Poderes e a Constituição do Estado Moderno: o papel do Poder Judiciário na obra de Montesquieu, escrito pela Advogada da União, Flávia Lima, trata de dissertar sobre as noções introdutórias da separação de poderes e liberdades políticas, sobretudo através da teoria de Montesquieu.

Disponível em:

https://www.academia.edu/31387968/A_Separa%C3%A7%C3%A3o_de_Poderes_e_a_Constitui%C3%A7%C3%A3o_do_Estado_Moderno_o_papel_do_Poder_Judici%C3%A1rio_na_obra_de_Montesquieu Acesso em nov. 2022.

Aula 3

O DIREITO NA ERA MODERNA

O Direito Moderno emerge das revoluções burguesas e das suas influências internacionais com a quebra do domínio religioso na política.

21 minutos

INTRODUÇÃO

O Direito Moderno emerge das revoluções burguesas e das suas influências internacionais com a quebra do domínio religioso na política. Nesse momento, há uma importante mudança no pensamento humano que traduz a racionalidade e o distanciamento com a Igreja, sobretudo o cristianismo das esferas políticas, jurídicas dentro da organização dos Estados.

Assim, com o surgimento do humanismo, desvincula-se o direito e a política dos mitos e predestinações da fé, passando-se a se defender que o homem é o verdadeiro condutor do seu próprio destino, dono de sua própria vontade e único dotado de razão para decidir o seu próprio futuro.

VAMOS ESTUDAR SOBRE A O *COMMON LAWE* E O *CIVIL LAW*?

O debate sobre as fontes do Direito e a influência de circunstâncias sociais e históricas remonta à tradição romanística (nações latino-germânicas) e à tradição anglo-americana (*common law*).

Na **tradição romanística**, há uma relevância do **processo legislativo**, com atribuição de valor secundário às demais fontes. Na **tradição anglo-americana**, por outro lado, o Direito é consolidado por meio de **precedentes judiciais** que se baseiam na relevância dos usos e dos costumes pela jurisdição, em oposição à abstração pretensamente geral e genérica, típica dos processos legislativos.

Embora não se possa conceber o Direito Romano como circunscrito em uma abstração racional típica do movimento codificador na modernidade, trata-se de um corpo jurídico que rompe com o Direito como objeto

composto tão somente pelos usos e costumes. Por essa razão, marca o início do Direito Natural que servirá de substrato teórico à construção do Direito Positivo enquanto síntese universalizável da razão humana.

Eduardo Bittar (2019) ressalta, também, que, no Direito Romano, os costumes, aos poucos, foram cedendo lugar à jurisdição ou ao direito jurisprudencial. Foi mediante a atividade dos juízes e dos pretores que os romanos construíram o *jus civile*, privativo dos romanos, e o *jus gentium*, de caráter mais amplo. Dessa forma, o direito próprio dos romanos (*jus civile*) foi se convertendo no Direito comum a romanos e estrangeiros: o Direito das gentes (*jus gentium*). Posteriormente, dada a influência da filosofia grega e estoica, a ideia de *jus gentium* se alargou em uma noção de valor universal que compõe o *jus naturale*, o Direito Natural.

Mesmo na tradição anglo-americana, nenhum costume obriga enquanto não consagrado pelos tribunais. Nesse sentido, Soares (2019) expressa que, seja em países onde há o primado da lei (*civil law*) ou em países onde há o primado do precedente judicial (*common law*), normas editadas pelo Estado têm prevalência sobre as demais normas jurídicas consideradas no ordenamento.

Nesse sentido,



É preciso lembrar também que a *Common Law* apresenta alguns traços de distinção fundamental em comparação imediata com a *Civil Law* (o Sistema Romano-Germânico de Direito). Um dos mais evidentes, diga-se, desde pronto, consiste no reconhecimento da fonte do direito a alcançar maior primazia neste sistema: enquanto na *Common Law* ocorre a consagração do precedente judiciário, gerado pelo costume, em sua congênere supracitada prepondera, de modo quase absoluto, a lei. Por isso mesmo se diz que o Direito inglês é uma espécie de “*judge made law*” (“direito construído por juízes”). Isso não quer de modo algum dizer que “não existam leis escritas” no país.

— (PALMA, 2019, p. 480)

Em linhas gerais, as diferenças entre os sistemas podem ser assim sintetizadas:

	<i>Civil law</i>	<i>Common law</i>
Fonte de direito predominante	Lei.	Jurisprudência.
Codificação	Existente, e a lei é a principal fonte de direito.	O direito não é codificado.
Papel dos precedentes	Em regra, não vinculantes.	Vinculantes.
Papel dos juízes	Os juízes devem, em suma, analisar os fatos para <i>aplicar</i> a norma codificada.	Os juízes <i>criam</i> o direito a partir da análise do conflito.

AS PECULIARIDADES DO DIREITO FEUDAL, DO DIREITO CANÔNICO E O SURGIMENTO DO

RENASCENTISMO

O common law é um direito essencialmente jurisprudencial em longo desenvolvimento nos séculos, sobretudo, na Inglaterra. Inclusive, ressalta-se que o Direito Inglês não sofreu as influências das codificações, nem renovado pela crescente retomada ao Direito Romano. Pelo contrário, manteve uma continuidade histórica dentro da sequência de julgados que compõe o common law.

Uma interessante característica do common law é o papel preponderante dos juízes, tendo em vista que são eles que elaboram as jurisprudências que serão posteriormente seguidas e usadas como fonte principais de Direito. É, pois, a característica fundamental do *commom law* ser um direito jurisprudência, de modo que a lei exerce um papel muito menos relevante, sendo resguardada ao momento de formação com os documentos constitucionais, entre outros. No entanto, no decorrer do desenvolvimento e da aplicação do *commom law* raramente é utilizada, sendo protagonizado pelas jurisprudências e juízes.

Alguns elementos importantes do common law é o *writ*, *equity*, *jury* e precedente judiciário. O writ é uma forma de qualquer cidadão peticionar frente às autoridades. Com a proibição dos writs surgiram os *equity* também com a proposta de se recorrer diretamente ao rei, nesse processo, era decidido conforme a equidade.

O *jury*, por sua vez, refere-se a presença de um júri no julgamento de diversos casos, inclusive da seara cível. Por fim, o precedente judiciário diz respeito aos casos julgados anteriormente que são frequentemente utilizados nas argumentações de defesa ou de denúncia.

Quanto ao civil law trata do direito ocidental, regulado pela linguagem predominante escrita, intensa codificação e extremo formalismo.

Miguel Reale (2002) esclarece que cada sistema é fruto de uma tradição social, cultural e histórica particular e, portanto, não se pode comparar *civil law* e *common law* qualitativamente fora do contexto em que cada sistema opera. Em primeiro lugar, é importante destacar que são dois sistemas jurídicos distinto e extremamente relevantes no mundo Ocidental, e que surgem, através de experiencias culturais diferentes. Ademais, é pouco interessante as discussões acerca das hierarquias dos dois sistemas, tendo em vista que inexistente um sistema perfeito de Direito, já que o próprio Direito ideal é uma falácia. O Direito, na realidade, representa uma experiência história de seu povo. Essa experiência notadamente é diversa entre as inúmeras nações existentes, dessa forma, para alguns a aplicação dos usos e costumes torna-se mais relevante, por ser uma aspiração imediata de seu povo, enquanto para outros existe um maior incentivo às legislações e formalismos legalistas, em razão de convicções políticas e filosóficas compartilhadas. No entanto, o mais importante é que na atualidade ambos os sistemas dialogam entre si, de modo que os precedentes judiciais vêm ganhando relevância dentro dos sistemas civilistas e as normas legais ganham cada vez mais importância nos sistemas de *common law*.

COMMON LAW E CIVIL LAW PELO MUNDO

O common law, como estudado, surgiu na Inglaterra por uma série de fatores, dentre eles a ausência das fortes influências do Direito Romano, que impões em grande parte do mundo o sistema germânico romano, bem como uma cultura de precedentes jurídicos já bem estabelecida. No entanto, o common law não se

restringiu aos territórios ingleses, pelo contrário, conseguiu se espalhar para outros países, ganhando força e relevância assim como o civil law.

A expansão do *common law* para outras partes do mundo ocorreu, sobretudo, em razão do programa de expansão colonial do Império Britânico que se intensifica, preponderantemente, no decorrer dos séculos XVIII e XIX. É por essa razão que países como os Estados Unidos da América, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a Irlanda e Gales, além de outros mais, estão filiados à grande família de Direito da Common Law, tendo em vista que foram, em determinado momento, colônias da Inglaterra.

Tanto o common law e o civil law produziram uma vasta tradição jurídica, atualmente vigente em vários países. Historicamente, o *civil law* corresponde a uma matriz latino-germânica do Direito, ao passo que o *common law* deriva da tradição anglo-americana. Atualmente, embora haja mútua influência entre os sistemas, pode-se identificar países em que um deles prevalece sobre o outro.

Conforme exposto, o sistema *civil law* funda-se, precipuamente, na lei como fonte de Direito. O sistema de *common law*, por sua vez, prioriza as decisões judiciais. Os demais sistemas representados, conforme evidenciado no mapa, são minoritários e têm aplicação pontual e, por isso, não são o foco desse estudo. Apenas a título de curiosidade, cabe ressaltar que o *customary law* (direito consuetudinário) funda-se no costume como fonte de Direito. O *muslim law* (ou xaria, direito islâmico), por sua vez, busca nas Escrituras Sagradas do Islamismo a fonte do Direito. Por fim, os países representados como *mixed systems* são aqueles em que se verifica um ou mais sistemas. Justamente pela influência territorialmente restrita, esses últimos sistemas não assumem grande relevância em nossos estudos, mas, cabe ressaltar, ainda assim, que cada um preserva grande importância histórica e cultural onde são aplicados.

Quanto às produções ou casos importantes, no civil law destacamos o *Corpus Juris Civilis*, Lei da XII Tábuas, Código de Manú, Código de Justiniano, Código de Napoleão e demais códigos modernos.

Quanto ao common law, podemos destacar as decisões da Suprema Corte Americana, como nos casos a seguir:

- a) Marbury contra Madison (1803): estabeleceu o princípio da revisão judicial.
- b) Gibbons contra Ogden (1824): ampliando a possibilidade do Congresso regulamentar o comércio
- c) Dred Scott contra Sandford (1857): que impedia um homem negro que havia mudado para um Estado livre, de deixar de ser considerado escravo. Tal decisão, inclusive, foi posteriormente revogada pela 13ª Emenda.

VÍDEO RESUMO: O DIREITO NA ERA MODERNA

Entende-se por commonw law o sistema jurídico utilizado por países de língua inglesa (anglo-saxões), que possui como característica fundamental o sistema de precedentes extraídos dos casos jurídicos concretos e não necessariamente por códigos; por outro lado, o civil law pode ser entendido como modelo de justiça em que a aplicação das normas se dá pela interpretação da lei escrita, com exemplos de como essa dicotomia, nos tempos contemporâneos, passa por uma “crise”, tendo-se em vista que em alguns sistemas, inclusive o brasileiro, existe a utilização desses dois modelos ao mesmo tempo.

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.969.03.PDF Acesso em nov. 2022.

de uma série de outras revoluções, de mesma inspiração, que eclodiram em toda a Europa no século XIX, a exemplo da Revolução Liberal do Porto (1820).

O que caracteriza, de um modo geral, as Revoluções Liberais é a reação contra o **absolutismo** e a defesa de uma plataforma política de cunho liberal, em favor da garantia de uma série de direitos civis, políticos e econômicos, protegendo o indivíduo em face do poder opressivo do Estado.

Para compreender o fenômeno dessas Revoluções, é preciso ter ciência de que a transição da Idade Média para a Idade Moderna teve como uma de suas características a substituição da multiplicidade de ordens políticas – típica do sistema feudal – pela unidade em torno de um poder político central, o que possibilitou o surgimento do Estado, tal como ele é conhecido a partir da Modernidade.

O Estado Moderno, entretanto, nasce com perfil absolutista, concentrando poderes nas mãos do monarca, de modo a possibilitar a imposição de uma única ordem política e jurídica e o estabelecimento de uma soberania, tanto interna quanto externamente. Dessa forma, o nascente Estado Moderno irá manter, inicialmente, uma série de privilégios remanescentes do Antigo Regime, favorecendo, sobretudo, a nobreza e o clero. Assim, o descontentamento da emergente burguesia e das camadas populares com a falta de participação política irá eclodir na forma de processos revolucionários liberais.

As Revoluções Liberais, além de introduzirem profundas transformações sociais e políticas, trouxeram importantes modificações no campo jurídico, que viriam a impactar decisivamente no Direito Moderno. Uma dessas mudanças é vislumbrada no forte intuito de codificar o Direito, sobretudo o Direito Privado ou Civil. Nesse sentido, Palma (2019) destaca a relevância dos movimentos de compilações do Direito Privado, o esforço trabalho no processo de sistematização jurídica ganha maior expressividade a partir de meados do século XVIII e é fundado pela dogmática e metodologia nascida no Lácio, porém não hesitava em mostrar-se inteiramente renovado pela atualização hermenêutica caracterizadora dos novos tempos. A importância desse movimento de codificação era tamanha, pois representava a criação de um sistema formal legal e jurídico, com bases de um positivo incipiente ainda, por isso, alguns autores afirmam, com razão, que o surgimento dos códigos jusnaturalistas foi um ato de transformação revolucionária.

AS PECULIARIDADES DAS REVOLUÇÕES LIBERAIS, DAS CODIFICAÇÕES DO DIREITO E DO CONSTITUCIONALISMO

As Revoluções Liberais foram marcadas pela criação de declarações de direitos, documentos normativos de inspiração jusnaturalista, que, embasados pelos ideais revolucionários, afirmavam a existência de uma série de direitos e liberdades fundamentais. Observe-se que tais documentos não se propuseram a criar direitos, mas declarar direitos que, *de per se*, seriam inerentes a todos os indivíduos.

O resultado das revoluções foi a expressão dos marcos iniciais do constitucionalismo moderno, entendido como: Movimento político-social que historicamente quis limitar o poder arbitrário; Exigência de Constituição escrita; Função e posição da Constituição na sociedade; Evolução histórico-constitucional no Estado.

A identificação com a primeira acepção é a mais corrente nos autores. Por exemplo, Nunes Júnior (2021, n.p.) usa conceito semelhante, afirmando que o constitucionalismo é o "movimento social, político e jurídico, cujo principal objetivo é limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição".

Mas não se trata de apenas um movimento, senão de vários movimentos constitucionais, que envolvem aspectos políticos, sociais e jurídicos (TAVARES, 2021) e que ocorreram em vários contextos históricos e

geográficos diferentes como, por exemplo, os constitucionalismos americano, francês, inglês e latino-americano (PUCCINELI JÚNIOR, 2015).

Segundo Martonio Mont'Alverne Barreto Lima, em verbete do Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional, obra coordenada por Dimoulis (2012), constitucionalismo é o resultado de acúmulo teórico do estudo das constituições e de seu desenvolvimento na história.

De forma sintética, o constitucionalismo pode ser conceituado como: Técnica específica de limitação do poder, indispensável à garantia dos direitos fundamentais e que inviabiliza a prevalência de interesses particulares na condução do Estado (LENZA, 2021).

Desse modo, o constitucionalismo, lado a lado das codificações do Direito, levou a modificações substanciais das instituições jurídicas, que se aplicam, em grande medida, até hoje. Afinal, no modelo atual ainda se busca, por exemplo, limitar o poder do Estado, garantir direitos fundamentais e fortalecer a democracia.

Ressalta-se que a unificação e uniformização do Direito foi outro efeito posterior às revoluções, já que: “com o iluminismo no século XVIII e a vitória burguesa na Revolução Francesa buscou-se a segurança em altíssimo grau, principalmente para defender a propriedade” (MACIEL, 2022, p. 417). O Direito foi, então, reduzido ao legal, com a supervalorização da lei como sendo sua legítima expressão.

Dessa forma, aliou-se a codificação e o constitucionalismo. O último tinha como objetivo a limitação do poder e a garantia dos direitos. Tal medida se impôs em decorrência das inúmeras revoluções liberais que traziam como bandeira o fim do poder absoluto e despota. Ademais, as revoluções apresentavam uma série de direitos e reivindicações legais, como a liberdade e a igualdade, o direito universal ao voto, entre outros. Essas demandas eram expressões do novo constitucionalismo que surgia, através dos esforços sociais e também de codificações e uniformizações do direito.

AS REVOLUÇÕES LIBERAIS E A BASE DO CONSTITUCIONALISMO MODERNO

Conforme vimos, o desdobramento das revoluções liberais impulsionou uma mudança na ótica jurídica, operada no seio do recente Estado Moderno. Tornou-se, portanto, uma urgência a definição e estruturação do direito que regeria cada Estado, diante disso, é interessante notar que cada região, marcada por seus distintos movimentos sociais e questões políticas, instaurou ordens e documentos, apesar de semelhantes em muitos aspectos, específicos aos seus contextos. Vamos estudar na prática como se deu o processo das revoluções e codificações dos direitos em alguns países marcantes.

No caso da Revolução Americana, os documentos jurídicos ali produzidos são considerados a base do constitucionalismo moderno, tendo em vista que a “Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia”, adotada aos 12 de junho de 1776 na Convenção realizada em Williamsburg foi um dos documentos mais marcantes dentro do movimento constitucionalista, capaz de influenciar diversas nações por todo o mundo. A Declaração da Virgínia (1776) trouxe, dentre suas prescrições, a liberdade religiosa, de culto e de consciência (artigo 18), a liberdade de imprensa (artigo 14), a tripartição de poderes (artigo 5º), o direito de propriedade (artigos 1º e 7º), o devido processo legal (artigos 10 e 12), dentre outros direitos.

Com fundamento na Declaração da Virgínia, posteriormente foi elaborada a Constituição dos Estados Unidos da América (1787), aprovada pela Convenção da Filadélfia, que viria a influenciar decisivamente o Direito Público moderno.

Já no contexto da Revolução Francesa, o principal documento jurídico elaborado foi a Declaração dos Direitos

do Homem e do Cidadão (1789), aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte. A Declaração é composta por 17 artigos e representou um grande marco na história moderna dos Direitos Humanos, tendo em vista que é inspirada pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, lema da Revolução.

Ressalta-se que, inclusive, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) possui extrema relevância no âmbito internacional, tendo em vista que compõe a trajetória do desenvolvimento dos Direitos Humanos, sendo um dos primeiros documentos a refletirem a proteção efetiva a determinados direitos dessa ordem.

Apesar de inspirada na Declaração da Virgínia, a Declaração francesa optou por adotar um caráter universalista em relação aos direitos ali previstos. Assim, o espírito da Revolução Francesa iria se espalhar rapidamente pelo mundo: “e, efetivamente, o espírito da Revolução Francesa foi difundido, em pouco tempo, não só na Europa, como também em regiões tão distantes quanto a Índia, a Ásia Menor e a América Latina” (COMPARATO, 2019, p. 223). No entanto, a violência política trazida pelo processo revolucionário terminaria por suprimir temporariamente alguns dos princípios e direitos trazidos pela Declaração.

De todo o modo, as declarações de direitos das Revoluções Liberais contribuíram para moldar o Direito Moderno, inaugurando uma tradição constitucionalista moderna, consolidando a proteção dos direitos fundamentais e estabelecendo garantias elementares como a igualdade jurídica, o devido processo legal, a separação de poderes, dentre outras.

VÍDEO RESUMO: O DIREITO NA ERA MODERNA (TEÓRICO)

O constitucionalismo moderno é resultado de um processo de ruptura ocorrido no final do século XVII e XVIII, representado pelas revoluções liberais burguesas na Inglaterra, Estados Unidos da América e França. Além da ruptura e permissão para a criação de um novo modelo de Estado, deu-se início a trajetória para a construção do Estado Constitucional. Destaca-se três importantes codificações que demonstram o movimento, quais sejam, Bill of Rights (1689), Declaração de Independência das treze colônias (1776) e a Declaração do Homem e do Cidadão (1789).

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

Saiba mais

Você deve saber que, em 2015, foi decretado e sancionado um novo Código de Processo Civil. Dentre as diversas inovações incorporadas ao Código, destaca-se a importância dada aos precedentes, que valorizam a jurisprudência como fonte de Direito. Nesse sentido, estaríamos diante de uma aproximação entre os sistemas jurídicos da civil law e da common law? No artigo “A força dos precedentes no Novo Código de Processo Civil”, de autoria de Elpídio Donizetti,, você aprofundará seus conhecimentos sobre os sistemas e poderá avaliar as inovações legislativas no âmbito processual civil.

DONIZETTI, Elpídio. A força dos precedentes no Novo Código de Processo Civil. Revista Direito UNIFACS, n. 175, 2015.

Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/3446/2472> . Acesso em: nov. 2022.

REFERÊNCIAS

27 minutos

Aula 1

MACIEL, José Fábio Rodrigues; AGUIAR, Renan. **Manual de História do Direito**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Cap. 7.4 “O Feudalismo e o Direito Feudal” (inteiro).

PALMA, R. F. **História do direito**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. E-book, “CAPÍTULO XI”

Aula 2

CICCO, Cláudio de. **História do Direito e do Pensamento Jurídico**. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Parte III, Cap. II “A Política do Absolutismo e o Direito Divino dos Reis”.

BONAVIDES, Paulo. **Ciência política**. São Paulo: Malheiros, 200, p. 150-202.

STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luís. **Ciência política e teoria do estado**. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2019, p. 12-67.

Aula 3

MACIEL, José Fábio Rodrigues; AGUIAR, Renan. **Manual de História do Direito**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Cap. 10 O sistema common law.

BITTAR, Eduardo Carlos B. **Introdução ao Estudo do Direito: humanismo, democracia e justiça**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

PALMA, R. F. **História do direito**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. E-book, “CAPÍTULO XI”

REALE, Miguel. **Lições Preliminares de Direito**. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

SOARES, Ricardo Maurício Freire. **Teoria Geral do Direito**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

Aula 4

COMPARATO, Fábio Konder. **A afirmação histórica dos direitos humanos**. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. Cap. 4 e 5.

MACIEL, José Fábio Rodrigues. **Manual de História do Direito**. 10. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2022. Cap. 13 “Estado Moderno: Unicidade X Pluralismo”, item 6.

PALMA, Rodrigo Freitas. **História do Direito**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2022. Parte 7, Cap. 17 e 18.